

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

**nr. 248.838 van 5 november 2020
in de zaak A. 228.080/XII-8735**

In zake: de BVBA COMMON GROUND
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Benito Boone
kantoor houdend te 2930 Brasschaat
Klaverweide 8
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Jens Debièvre en Ruben Dewulf
kantoor houdend te 1000 Brussel
Havenlaan 86c, 113b
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van het beroep

1. Met een verzoekschrift, ingediend op 10 mei 2019, vordert de
bvba Common Ground een schadevergoeding tot herstel naar aanleiding van het
arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord
ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord
ingediend.

Eerste auditeur Inge Vos heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 8 september 2020.

Staatsraad Patricia De Somere zet de stand van de zaak uiteen.

Advocaat Benito Boone, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Jens Debièvre, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit met als voorwerp het verrichten van “diensten te leveren door een communicatiebureau gespecialiseerd in de communicatie en in het beheer van informatie rond grote infrastructuurprojecten met de bedoeling de communicatie rond de werf Metro Bordet-Albert te realiseren en te beheren gedurende de hele duur van het project”.

De gunningswijze is de onderhandelingsprocedure met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst.

De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

3.2. Op 21 februari 2017 selecteert de verwerende partij vijf ondernemingen en stelt zij het bestek vast.

3.3. Twee ondernemingen dienen een offerte in, namelijk de nv Dialogic Agency en de tijdelijke vennootschap samengesteld uit de verzoekende partij en de bvba Prophets.

3.4. Op 24 oktober 2017 gunt de verwerende partij de opdracht aan de nv Dialogic Agency.

3.5. Met een brief van 30 oktober 2017 maakt de verzoekende partij bezwaren over aan de verwerende partij betreffende de gunningsbeslissing, waarop de verwerende partij schriftelijk reageert. Vervolgens vindt er nog briefwisseling tussen de partijen en tussen hun raadslieden plaats.

3.6. Op 28 november 2017 beslist de verwerende partij overeenkomstig artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, haar gunningsbeslissing van 24 oktober 2017 in te trekken en de lopende opdrachtprocedure stop te zetten.

3.7. Op 26 januari 2018 dient de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State tegen de voormelde beslissing van 28 november 2017.

3.8. Bij arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019 heeft de Raad van State het annulatieberoep verworpen op grond van de volgende overwegingen:

“8. De verzoekende partij heeft samen met de bvba Prophets een offerte ingediend bij de plaatsingsprocedure voor de kwestieuze overheidsopdracht. Zij heeft haar beroep bij de Raad van State echter alleen ingediend.

9. Zoals de verzoekende partij uitdrukkelijk in haar inleidend verzoekschrift heeft vermeld, beoogt zij met haar beroep de overheidsopdracht die het voorwerp is van de betwiste plaatsingsprocedure, in de wacht te slepen. Bij een nietigverklaring van de stopzettingsbeslissing en op grond van de motieven bij dergelijk arrest meent de verzoekende partij een kans te hebben de opdracht gegund te krijgen als inschrijver ‘met de enige regelmatige, economisch meest voordelige offerte’.

10. De rechtspraak van de Raad van State is in die zin gevestigd dat in principe alleen degenen die regelmatig kandidaat geweest zijn voor het uitvoeren van een overheidsopdracht over de vereiste hoedanigheid en een voldoende persoonlijk en rechtstreeks belang beschikken om de nietigverklaring na te streven van de beslissing die de betrokken opdracht aan een andere kandidaat, of, zoals te dezen, aan niemand gunt. Immers, zoals de Raad van State reeds heeft gesteld onder meer in zijn arresten nrs. 152.172 en 152.174 van 2 december 2005 van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, strekt het beroep bij de Raad van State tegen een beslissing inzake de toewijzing van een overheidsopdracht, er idealiter toe de verzoekende partij een nieuwe kans te verschaffen om de opdracht zelf gegund te krijgen en zelf uit te voeren. Toegepast op onderhavige zaak, moet aldus worden vastgesteld dat het niet de verzoekende partij is die – alleen optredend – een offerte heeft ingediend in de plaatsingsprocedure. Integendeel is de offerte ingediend door de verzoekende partij samen met de bvba Prophets. Bijgevolg zijn het slechts beiden samen optredend, die over de vereiste hoedanigheid en het belang beschikken om het huidig beroep in te dienen.

Een annulatieberoep tegen een bestreden stopzettingsbeslissing kan slechts ontvankelijk worden ingesteld door alle ondernemingen die samen de offerte hebben ingediend. Alleen handelend, mist te dezen de verzoekende partij aldus de vereiste hoedanigheid en het rechtens vereiste persoonlijk en rechtstreekse belang daartoe.

11.1. De verzoekende partij merkt in haar laatste memorie in de eerste plaats op dat de hiervoor in herinnering gebrachte rechtspraak van de Raad van State niet van toepassing is omwille van bepaalde omstandigheden. Deze argumentatie wordt niet aanvaard om volgende redenen.

11.2. Het feit dat de verwerende partij een actieve en een beroep ontradende rol zou hebben gespeeld ten aanzien van de mede-inschrijver, de bvba Prophets, is irrelevant ten aanzien van de hoedanigheid en het

belang van de verzoekende partij, voorwerp van een exceptie die ook ambtshalve wordt onderzocht.

11.3. De verzoekende partij maakt voorts niet afdoende duidelijk waarom het feit dat de bestreden beslissing hier niet een gunningsbeslissing is doch een stopzettingsbeslissing, waarbij de verzoekende partij als bestreden beslissing ook de niet-gunning aan haar aanwijst, haar wel de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang oplevert.

11.4. Evenmin toont de verzoekende partij aan dat het feit dat er nog geen tijdelijke vennootschap is opgericht tussen de verzoekende partij en de bvba Prophets bepalend is voor haar hoedanigheid en belang. Relevant is hier immers dat zij niet alleen de offerte heeft ingediend.

12.1. Ondergeschikt meent de verzoekende partij in haar laatste memorie dat de ingeroepen rechtspraak van de Raad van State achterhaald is. Die opvatting wordt evenmin bijgevallen om de volgende redenen.

12.2. De rechtspraak van de Raad van State is onder meer gegrond op het arrest Espace Trianon sa e.a. van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 september 2005, zaak C-129/04, waarin het Hof voor recht verklaart dat artikel 1 van de voormelde richtlijn 89/665/EEG er niet aan in de weg staat dat naar nationaal recht alle leden van een tijdelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die als zodanig heeft deelgenomen aan een plaatsingsprocedure en waaraan deze opdracht niet is gegund, beroep kunnen instellen tegen de gunningsbeslissing, en niet slechts één van haar leden individueel.

De Raad ziet niet in hoe het voormelde arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie inzake European Dynamics Luxembourg sa van 23 mei 2014, gevelde binnen het in het Gerecht geëigende rechtskader, tot een wijziging van de rechtspraak van de Raad inzake hoedanigheid en belang in deze problematiek zou moeten leiden.

Evenmin laat de zinsnede ‘elke persoon die een belang heeft of heeft gehad om een bepaalde opdracht of concessie te krijgen’ zoals terug te vinden in de voormelde wet van 17 juni 2013 of in de voormelde richtlijn 89/665/EEG anders oordelen. De verzoekende partij heeft geen offerte ingediend alleen handelend en kan dus niet worden geacht een belang te hebben of te hebben gehad om de kwestieuze opdracht gegund te krijgen. Aan haar alleen mocht de opdracht niet worden gegund.

12.3. Het gegeven dat de Raad thans beschikt over de bevoegdheid tot het toekennen van een schadevergoeding tot herstel is evenmin bepalend om de rechtspraak te wijzigen.

In de eerste plaats vordert de verzoekende partij geen schadevergoeding. Voorts is het beroep van de verzoekende partij ab initio onontvankelijk wat nochtans een voorwaarde is om een schadevergoedingsvordering te mogen instellen.

De verzoekende partij kan haar subjectief recht op schadevergoeding overigens bij de gewone rechter laten gelden.

12.4. De verwijzing door de verzoekende partij naar bepaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie overtuigt evenmin.

In de aangehaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie ging het over zaken waarin deelgenoten van een tijdelijke handelsvereniging schadevergoeding vorderden uit hoofde van een handelsovereenkomst en waarbij het Hof lijkt te oordelen dat de vordering van één van de deelgenoten ontvankelijk is ten belope van zijn eigen aandeel in de vennootschap. Het gaat om een subjectief recht op schadeloosstelling die toekomt pro parte aan elk van de vennoten.

Te dezen echter kadert een annulatieberoep bij de Raad in een objectief contentieux waarbij de vernietiging van de bestreden beslissing wordt nagestreefd en waarbij vereist is dat de verzoekende partij belang heeft. De bestreden beslissing kan hier niet worden opgedeeld per inschrijver; er werd één offerte ingediend door twee inschrijvers waaronder de verzoekende partij; in de optiek van de voormelde rechtspraak van de algemene vergadering vermeld sub randnummer 10, waarbij het belang gesitueerd wordt in een nieuwe kans om de opdracht zelf gegund te krijgen en uit te voeren, kan een annulatie hier niet worden beperkt tot het aandeel van de verzoekende partij. In wezen is het geschil, wat het belang betreft, hier een onplitsbaar geschil.

13. De verzoekende partij vraagt aan de Raad de voormelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Zoals de Raad reeds heeft geoordeeld in het arrest nr. 194.336 van 18 juni 2009, *nv Ecorem e.a.*, en in het arrest nr. 209.130 van 24 november 2010, *nv Eurosense Planning en Engineering e.a.*, is de hier gestelde vraag in wezen gelijk aan een vraag die reeds in een gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest, namelijk de vraag beantwoord in het arrest *Espace Trianon sa e.a.* van 8 september 2005, zaak C-129/04. De omstandigheid dat de Raad thans bevoegd is om schadevergoeding tot herstel toe te kennen, leidt niet tot een ander oordeel. De verzoekende partij vraagt geen schadevergoeding. Voorts mag er slechts een schadevergoeding worden toegekend voor zover het beroep ontvankelijk werd ingesteld, wat hier niet het geval is.

14. In de mate dat de verzoekende partij de Raad vraagt een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, dient er evenmin op te worden ingegaan.

Zoals reeds meermaals opgemerkt vordert de verzoekende partij geen schadevergoeding. Voorts maakt de verzoekende partij niet duidelijk dat de te vergelijken categorieën, namelijk een verzoekende partij in dan wel buiten het overheidsopdrachtencontentieux, vergelijkbare categorieën zijn. De verzoekende partij brengt overigens helemaal geen rechtspraak van buiten het contentieux van de overheidsopdrachten bij.

15. Ten slotte vraagt de verzoekende partij de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering van de Raad van State om de eenheid van rechtspraak te vrijwaren aangezien er volgens haar uiteenlopende rechtspraak is binnen de Raad omtrent het in rechte treden van 'deelgenoten van een tijdelijke vereniging'.

Ook hier gaat de Raad niet op in. Zoals sub randnummer 14 aangegeven, laat de verzoekende partij na andersluidende rechtspraak dan die vermeld

sub randnummer 10 in met het overheidsopdrachtencontentieux vergelijkbare zaken op te geven.

16. De exceptie is gegrond en het beroep wordt verworpen.”

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging

A. Pleitnota

4. De verzoekende partij heeft op 1 september 2020 een pleitnota met aanvullende stukken aan de Raad van State bezorgd.

Deze pleitnota strekt ertoe “nog op nuttige wijze te reageren op de laatste memorie van de verwerende partij, alsook op het nieuwe stuk 16 dat zij daarbij heeft neergelegd (niet-gepubliceerd arrest van 20 september 2019 van het Hof van Beroep te Gent)”.

5. Het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’ (hierna: het algemeen procedurereglement) voorziet niet in de mogelijkheid om een pleitnota als een processtuk neer te leggen. Het is de partijen echter wel toegestaan om nieuwe feiten die een invloed kunnen hebben op de ontvankelijkheid of de gegrondheid van het beroep, aan de Raad van State ter kennis te brengen.

In zoverre de door de verzoekende partij neergelegde pleitnota op dergelijke feiten betrekking heeft, wordt ze dan ook bij de zaak betrokken. In zoverre de pleitnota geen betrekking heeft op dergelijke feiten, maar de neerslag vormt van de uiteenzetting ter terechtzitting, wordt ze niet als een processtuk, maar als een loutere inlichting in aanmerking genomen.

Evenwel blijkt niet dat de verzoekende partij haar bijkomende argumentatie die zij omtrent de beweerde schending van het recht op toegang tot

de rechter nog uiteenzet in haar pleitnota, evenals haar nieuwe vraag om de zaak met toepassing van artikel 92, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State te verwijzen naar de Algemene Vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State “om opnieuw een arrest te vellen in het kader van de toepassing van artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en de toepassing daarvan op het overheidsopdrachtencontentieux” niet eerder ontvankelijk kon aanvoeren, zodat het vooralsnog nader onderzoek ervan het recht op tegenspraak van de verwerende partij op onevenredige wijze zou beperken.

B. Samenvoeging

Standpunt van de verzoekende partij

6. De verzoekende partij wijst er in de laatste memorie op dat er nog een nietigheidsprocedure met rolnummer A. 224.379/VI-21.182 hangende is tegen “de beslissing tot stop[z]etting” van de verwerende partij voor de VIe Kamer van de Raad van State, ingesteld door een andere inschrijver, met name de nv Dialogic Agency en waarin de verzoekende partij voorlopig is toegelaten om tussen te komen.

Zij betoogt dat overeenkomstig artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State niet alleen een verzoekende partij, maar ook een tussenkomende partij in een nietigheidsprocedure de mogelijkheid heeft om een schadevergoeding tot herstel te vorderen binnen de 60 dagen na het arrest waarin de onwettigheid van de bestreden beslissing werd vastgesteld. De vaststelling van de onwettigheid volstaat, zonder dat noodzakelijk de nietigheid dient te zijn uitgesproken. In dat licht vraagt de verzoekende partij, teneinde tegenstrijdige arresten te vermijden, de voorliggende vordering en de “parallelle” nietigheidsprocedure voor de VIe Kamer wegens verknochtheid naar één kamer te verzenden. Minstens dient de uitspraak in de voorliggende zaak te worden aangehouden totdat er een arrest is tussengekomen in de andere procedure.

Zij vraagt in dat verband ook een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, waarbij de verenigbaarheid van artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en meer bepaald hoe het verenigbaar is met de Grondwet “dat een ab initio onontvankelijke tussenkomst de tussenkomende partij toch toelaat om [in een parallelle zaak] een ontvankelijke vordering tot schadevergoeding tot herstel in te dienen bij de Raad van State, terwijl een ab initio onontvankelijk verzoekschrift tot nietigverklaring niet tot een ontvankelijke vordering tot schadevergoeding tot herstel kan leiden”.

Beoordeling

7. Er blijkt geen grond (meer) te zijn voor de gevraagde samenvoeging nu de nv Dialogic Agency bij brief van 20 maart 2020 afstand heeft gedaan van haar vordering.

De voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof is laattijdig want voor het eerst aangebracht in de laatste memorie zonder dat de verzoekende partij verduidelijkt waarom zij zulks niet eerder in de procedure kon hebben gedaan.

V. Ontvankelijkheid van het verzoek tot schadevergoeding tot herstel

Standpunt van de partijen

8. In het verzoekschrift zet de verzoekende partij uiteen dat, ondanks het feit dat de vordering in de voorafgaande nietigheidsprocedure onontvankelijk werd bevonden, de Raad van State desondanks wel rechtsmacht heeft en bevoegd is om kennis te nemen van de voorliggende vordering tot schadevergoeding, wat volgens haar tevens impliceert dat de middelen ten gronde wel dienen te worden onderzocht in het kader van de onderhavige schadevergoedingsprocedure.

Waar de wetgever krachtens artikel 144, tweede lid, van de Grondwet aan de Raad van State expliciet rechtsmacht heeft verleend om over de burgerrechtelijke subjectiefrechtelijke gevolgen te beslissen, kan – eventueel móét – de Raad zich volgens de verzoekende partij bevoegd verklaren om kennis te nemen van een verzoek tot schadevergoeding tot herstel.

9. Een eerste uitvoering van deze bepaling werd volgens haar gegeven met de invoering van artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het volstaat dat een verzoekende partij de nietigheid heeft “benaarstigd” en erom heeft “verzocht”, om vervolgens als “accessorium” van deze “principale” nietigheidsprocedure een schadevergoedingsprocedure te kunnen instellen bij dezelfde rechtbank, dit is de Raad van State. Deze mogelijkheid werd om proceseconomische redenen ingevoerd, om onnodige werklast te vermijden bij de burgerlijke rechtbanken, die zich volledig in het dossier zouden moeten inwerken. Zij wijst erop dat de Raad ondertussen enkele arresten heeft gewezen in algemene vergadering waarbij effectief wordt bevestigd dat er geen voorafgaande formele nietigverklaring vereist is om toch een evaluatie te verrichten van de (on)wettigheid van de bestreden handeling, en eventueel een schadevergoeding tot herstel toe te kennen. Zij erkent dat de Raad daarbij echter wel nog een slag om de arm houdt door deze mogelijkheid voorlopig voor te behouden aan (a) een verzoekende partij die haar (functioneel) belang heeft verloren in de loop van de nietigheidsprocedure zonder dat haar dit verwijtbaar is, (b) die nog tijdens de nietigheidsprocedure een schadevergoedingsvordering heeft ingediend en (c) indien haar vordering tot nietigverklaring *ab initio* ontvankelijk was.

10. Daarnaast heeft de wetgever volgens de verzoekende partij nog een andere toepassing gemaakt van artikel 144 van de Grondwet specifiek voor de verzoeken tot schadevergoeding inzake overheidsopdrachten, zodat de hiervoor genoemde beperkingen – die overigens in de rechtsleer bekritiseerd worden – niet van toepassing zijn op het voorliggende verzoek. Zij betoogt dat de artikelen 16 en 24 van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies' (hierna: rechtsbeschermingswet) de Raad van State als exclusief bevoegde rechtbank aanwijzen voor de beoordeling van een verzoek tot schadevergoeding mede wanneer de verwerende partij een administratieve overheid is. *In casu* is volgens de verzoekende partij voldaan aan de twee cumulatieve voorwaarden die in die wet worden gesteld aangezien: (a) de verwerende partij een "overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State" en (b) de verzoekende partij "een schadevergoeding tot herstel als bedoeld in artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State" heeft "gevorderd". Deze "lex specialis" heeft volgens haar voorrang op de "lex generalis", dit zijn de schadevergoedingen die als "accessorium" van alle nietigheidsvorderingen kunnen worden gevraagd bij de Raad van State met toepassing van het voormelde artikel 11bis. Bovendien hebben de bepalingen van de rechtsbeschermingswet volgens haar ook voorrang als "lex posterior".

De discussie aangaande het belang is volgens haar in het kader van de voorliggende vordering tot schadevergoeding eveneens niet meer aan de orde zoals in de voorafgaande annulatieprocedure, omdat dit belang in een schadevergoedingsprocedure immers buiten kijf staat, gelet op het arrest Club Hotel Loutraki van 6 mei 2010 van het Europees Hof van Justitie.

11. Ondergeschikt betoogt de verzoekende partij dat ook met toepassing van artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de voorliggende vordering tot schadevergoeding tot herstel ontvankelijk is omdat *in casu* ook rekening dient te worden gehouden met het feit dat het specifiek het overheidsopdrachtencontentieux betreft. Het recht op toegang tot de rechter wordt in deze zaak niet enkel beschermd door artikel 6, § 1, van het EVRM en artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, maar tevens door de rechtsbeschermingsrichtlijn 89/665/EEG. Artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State dient dus tevens richtlijnconform te worden toegepast.

Welnu, specifiek in het overheidsopdrachtencontentieux bij de burgerlijke rechtbanken, zijn er volgens de verzoekende partij ondertussen verschillende precedentes bekend waarbij de burgerlijke rechtbank een vordering tot schadevergoeding ongegrond verklaart indien niet eerst formeel de “nietigheid” werd gevorderd en verkregen met toepassing van de wet overheidsopdrachten, hetgeen precies door het Hof van Justitie in het arrest Club Hotel Loutraki als onverenigbaar met de rechtsbeschermingsrichtlijn werd bevonden.

Aangezien de Raad van State te dezen geen arrest *erga omnes* kan vellen dat de burgerlijke rechtbank ertoe verplicht haar voormelde rechtspraak aan te passen, rest er volgens de verzoekende partij geen andere optie dan het voorliggende verzoek tot schadevergoeding ontvankelijk te verklaren, hetzij eerst een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van (de huidige interpretatie van) artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State met de rechtsbeschermingsrichtlijn. De opmerking van de Raad van State in het arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019 dat “de verzoekende partij haar subjectief recht op schadevergoeding overigens bij de gewone rechter (kan) laten gelden”, lijkt in ieder geval voorbarig en niet gefundeerd in het licht van de voornoemde recente rechtspraak. De stelling van de Raad van State in het arrest nr. 244.015 van 22 maart 2019 inzake Moors lijkt volgens de verzoekende partij in strijd met een arrest van het Hof van Cassatie van 7 mei 2018. Het disproportionele karakter van het onderscheid tussen de verzoekende partijen die al dan niet tijdens de nietigheidsprocedure, dan wel nadien, een schadevergoeding instellen, wordt volgens haar nog versterkt door de eerder geciteerde burgerlijke rechtspraak. Het onderscheid dwingt de verzoekende partij bovendien om nog tijdens de vernietigingsprocedure een verzoek op grond van artikel 11*bis* in te dienen waardoor het electa-una-viaprincipe wordt geactiveerd. Het feit dat de verzoekende partij nog geen vordering tot schadevergoeding wenste in te dienen tijdens de nietigheidsprocedure, maar eerst het arrest daarin wenste af te wachten, is

volgens haar geen gegronde reden om haar nu de effectieve toegang te ontzeggen tot een verzoek tot schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State.

Voorts wijst de verzoekende partij er louter voor de volledigheid nog op dat, naast de reeds in de nietigheidsprocedure geciteerde rechtspraak T-553/11 van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie waar rekening werd gehouden met de rechtsbeschermingsrichtlijn, er op 17 januari 2019 een nieuw arrest is gewezen door hetzelfde Gerecht van Eerste Aanleg T-117/17 waarin de vordering tot nietigverklaring in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux ontvankelijk werd verklaard ook hadden niet alle leden van een consortium zonder rechtspersoonlijkheid deze vordering ingesteld.

12. De verwerende partij werpt in haar memorie van antwoord een exceptie van onontvankelijkheid van het verzoek tot schadevergoeding tot herstel op.

Daarbij betoogt zij vooreerst dat het verzoek niet werd ingediend op een van de drie, overeenkomstig artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, *juncto* artikel 25/1 van het algemeen procedurereglement, voorziene momenten.

Voorts betoogt de verwerende partij dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State eveneens gelden binnen het overheidsopdrachtencontentieux, en het standpunt van de verzoekende partij dat er slechts aan twee voorwaarden zou moeten worden voldaan, niet kan worden bijgevalen.

Het ontbreken van een arrest dat een onwettigheid vaststelt, leidt *in casu* wel degelijk tot de onontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding tot herstel en dat de verzoekende partij de nietigverklaring

heeft “benaarstigd” volstaat niet, zoals wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Ook een richtlijnconforme rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten noodzaakt volgens de verwerende partij niet de beoordeling van de voorliggende vordering tot schadevergoeding tot herstel.

De verwerende partij betwist ten slotte de relevantie van de door de verzoekende partij voorgestelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof.

13. In haar memorie van wederantwoord herhaalt de verzoekende partij dat de restrictieve interpretatie en rechtspraak van de Raad van State omtrent artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State *in casu* niet ter zake doen omdat artikel 24 van de rechtsbeschermingswet een aparte en voldoende rechtsgrond biedt voor het onderhavig verzoek tot schadevergoeding tot herstel en, subsidiair, ook artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in een grondwets- en richtlijnconforme interpretatie, tot de ontvankelijkheid van het voorliggend verzoek tot schadevergoeding tot herstel moeten leiden.

14. Waar de verwerende partij betoogt dat een andere interpretatie van artikel 24 van de rechtsbeschermingswet in strijd zou zijn met het grondwettelijk verbod op ongelijke behandeling, zet zij volgens de verzoekende partij niet uiteen waarin deze ongelijkheid zou bestaan, doch beperkt zij zich tot verwijzing naar een rechtsgeleerd artikel. Nadere lezing van dat artikel bevestigt net dat de voornoemde bepaling richtlijnconform moet worden toegepast en dat een te restrictieve interpretatie van het voornoemde artikel 11*bis* buiten toepassing moet worden gelaten. Volgens de verzoekende partij is er geen sprake van een ongelijkheid als de door de Raad van State ontwikkelde rechtspraak in het kader van artikel 11*bis* anders wordt toegepast in het overheidsopdrachtencontentieux aangezien deze materie zich voldoende

onderscheidt van andere materies. Zij verwijst daarbij naar rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, meer bepaald het arrest van 7 december 2005, nr. 179/2005, overweging B.10.2, evenals naar rechtspraak van de Raad van State. Meer nog, de ongrondwettige ongelijkheid heeft volgens haar betrekking op de discriminatoire behandeling van leden van een tijdelijke handelsvennootschap. Het door de verwerende partij geciteerde artikel bevestigt wel degelijk dat de rechtsbeschermingswet een “lex specialis” is ten aanzien van artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, hetgeen ook door de Raad reeds werd erkend in het arrest nr. 233.367 van 29 december 2015 aangaande het aanvangspunt van de beroepstermijn.

15. Voorts benadrukt de verzoekende partij dat relevante recente EU- en cassatierechtspraak zowel een impact hebben op het begrip “belang” in het annulatiecontentieux inzake overheidsopdrachten als op de ontvankelijkheid van een schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State. Daarbij verwijst zij naar het arrest van het Hof van Justitie van 29 juli 2019, nr. C-620/17 inzake Hochtief waarin wordt bevestigd dat een lidstaat aansprakelijk is voor de schade die wordt toegebracht indien een in laatste aanleg rechtsprekende nationale rechter een met een Unierechtelijke regel strijdige beslissing heeft genomen, en bovenal waarin wordt gesteld dat, voor zover het onder de toepasselijke nationale procedureregels mogelijk is om “terug te komen” op een in kracht van gewijsde gegane vonnis, het beginsel van loyale samenwerking zoals vervat in artikel 4, derde lid, van het “VWEU” de betrokken nationale rechter gebiedt van deze mogelijkheid gebruik te maken teneinde “de situatie in overeenstemming te brengen met het Unierecht, zoals uitgelegd in een eerder arrest van het Hof”.

Aangezien een richtlijnconforme interpretatie van artikel 24 van de rechtsbeschermingswet en artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot de mogelijkheden behoort, dient de Raad rekening te houden met de rechtspraak die is tussengekomen sinds de zitting van 17 januari 2019 in de voorafgaande nietigheidsprocedure. Het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 17 januari 2019, nr. T-117/17 inzake Proximus en het arrest

van het Hof van Justitie van 5 september 2019, nr. C-333/18 inzake Lombardi, laten de Raad volgens de verzoekende partij toe terug te komen op het arrest nr. 243.820, gewezen in het kader van het annulatieberoep. In het eerste arrest werd de vordering tot nietigverklaring in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux ontvankelijk verklaard, ook al hadden niet alle leden van een consortium zonder rechtspersoonlijkheid deze vordering ingesteld. Wat het tweede arrest betreft, verwijst de verzoekende partij meer bepaald naar volgende overweging:

“33. Wat tot slot het beginsel van procedurele autonomie van de lidstaten betreft, kan worden volstaan met eraan te herinneren dat dit beginsel hoe dan ook geen rechtvaardiging kan vormen voor bepalingen van nationaal recht die de uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken (zie in die zin arrest van 11 april 2019, PORR Építési Kft., C 691/17, EU:C:2019:327, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Om de in de bovenstaande punten van het onderhavige arrest uiteengezette redenen vloeit uit artikel 1, lid 1, derde alinea, en lid 3, van richtlijn 89/665, zoals uitgelegd door het Hof, voort dat een inschrijver die een beroep heeft ingesteld zoals dat aan de orde in het hoofdgeding, niet op grond van nationale procedurele regels of praktijken zoals die welke door de verwijzende rechter zijn omschreven, zijn recht op een onderzoek ten gronde van dat beroep kan verliezen.”

Aangezien bepaalde burgerlijke rechtbanken de voorafgaande nietigheid vereisen om nog een ontvankelijke procedure tot schadevergoeding te kunnen instellen, is het voor haar “in de praktijk” “uiterst moeilijk” om haar recht op schadevergoeding uit te oefenen.

De verzoekende partij verwijst nog naar de conclusie van advocaat-generaal Wathelet van 7 juni 2018 in de zaak C-300/17 van het Hof van Justitie waarin deze stelt dat “[a]rtikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [zich] verzet [...] tegen een nationale regeling die voor de instelling van een beroep tot schadevergoeding wegens inbreuk op een regel inzake overheidsopdrachten vereist dat vooraf wordt vastgesteld dat de procedure voor het plaatsen van de betrokken opdracht onrechtmatig was wanneer de persoon die schadevergoeding vordert, niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft

gehad om voor een nationale rechterlijke instantie het middel aan te voeren waarop hij zich ter ondersteuning van zijn schadevordering wenst te beroepen”.

Wat het arrest van het Hof van Cassatie van 7 mei 2018, nr. C.16.0516.F betreft, gaat het enige verweer van de verwerende partij, dat dit arrest handelt over de ontvankelijkheid van een annulatieberoep en niet over een vordering tot schadevergoeding tot herstel, volgens haar niet op in het licht van het voormelde arrest Hochtief van het Hof van Justitie.

16. Voorts verwijst de verzoekende partij opnieuw naar het recht op toegang tot de rechter zoals beschermd door artikel 6, § 1, van het EVRM, artikel 47 van het Handvest van de Europese Unie en de Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen.

Zij merkt op dat zij bewust geopteerd heeft om geen schadevergoeding tot herstel in te dienen tijdens de annulatieprocedure. Deze afweging was ook ingegeven door de opkomende rechtspraak van de burgerlijke rechtbanken die tot de onontvankelijkheid besluit van schadeclaims indien deze niet zijn voorafgegaan door een effectieve nietigverklaring. Volgens haar zijn er ondertussen reeds vier vonnissen die deze strekking volgen. Zolang deze rechtspraak niet in beroep of cassatie werd herzien, kan het aan de verzoekende partij niet worden verweten dat zij het voorliggende verzoek tot schadevergoeding tot herstel indient bij de Raad.

Een verwerping van de voorliggende vordering louter op grond van een onontvankelijke nietigheidsprocedure zou in de gegeven omstandigheden volgens haar duidelijk in strijd zijn met de hoger genoemde fundamentele beginselen. Bij deze omstandigheden dient volgens haar tevens rekening te worden gehouden met het feit dat de verwerende partij druk heeft gezet op het andere lid van de tijdelijke vereniging om niet mee te stappen in de procedure tot nietigverklaring.

17. Na een voor haar negatief uitvallend auditorsverslag, waarin de auditeur besluit tot de onontvankelijkheid van de vordering, blijft de verzoekende partij er in de laatste memorie bij dat haar verzoek tot schadevergoeding tot herstel wel degelijk ontvankelijk is. Ze doet nog gelden dat de wetgeving en de rechtspraak die het recht op toegang tot een rechter beperken, duidelijk en voorspelbaar moeten zijn en van een verzoeker niet mag worden verwacht dat hij voldoet aan een ontvankelijkheidsvereiste waarvan hij de toepassing niet zou kunnen begrijpen of voorspellen. Dit houdt volgens haar ook in dat de rechtspraak coherent moet zijn, zonder echter het belang van de concrete omstandigheden uit het oog te verliezen maar ook de aandacht voor die concrete omstandigheden moet voorspelbaar zijn.

De verzoekende partij blijft er in de eerste plaats bij dat de vaststaande rechtspraak van de Raad van State waarbij één lid van een tijdelijke vereniging nooit op ontvankelijke wijze een vordering tot nietigverklaring, en daardoor noodzakelijkerwijze ook nooit een ontvankelijke vordering tot schadevergoeding tot herstel kan indienen bij de Raad van State, zonder daarbij rekening te houden met de concrete omstandigheden, op zich al strijdig is met het recht op toegang tot de rechter.

In het licht van de twee doelstellingen van artikel 19, eerste lid, en artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, met name het vermijden van de *actio popularis*, enerzijds, en de proceseconomische voordelen, anderzijds, maakt het volgens haar een manifeste schending uit van het recht op toegang tot de rechter als haar vordering tot schadevergoeding tot herstel onontvankelijk zou worden verklaard.

Zij wijst hierbij op de volgende volgens haar relevante concrete omstandigheden, die volgens haar moeten worden afgewogen ten aanzien van de doelstellingen die met de betrokken bepalingen worden nagestreefd: het concrete gegeven dat de verwerende partij dwang had uitgeoefend op het andere lid van de tijdelijke vereniging (de bvba Prophets) om af te zien van een procedure tot

nietigverklaring, de rechtspraak van de lagere rechtbanken – ook al lijkt die in strijd met de toepasselijke wetgeving – waarbij een vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen indien er geen nietigheidsbeslissing voorligt (die *in casu* enkel en alleen bij de Raad van State kan worden verkregen), het advies van het auditoraat in het kader van de nietigheidsprocedure dat de vaststaande rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de ontvankelijkheid van de nietigheidsvordering van een lid van een tijdelijke vereniging strijdig is met internationale rechtspraak, de incidentie van de door de nv Dialogic Agency ingestelde nietigheidsprocedure met hetzelfde voorwerp die voor de VIe Kamer van de Raad hangende is, waarin de verzoekende partij is tussengekomen, de verschillen tussen een burgerlijke procedure tot schadevergoeding en een herstellvordering bij de Raad van State en de verschillende kosten in de beide procedures.

Zij besluit dan ook dat het niet ontvankelijk verklaren van de voorliggende vordering op geen enkele wijze nuttig bijdraagt tot het vermijden van een *actio popularis* en bovendien past de ontvankelijkheid ook in de proceseconomische overwegingen die de wetgever ertoe heeft geleid de Raad van State rechtsmacht te verlenen in het kader van een schadevergoeding tot herstel.

In de tweede plaats blijft zij erbij dat er wel degelijk noodzaak is tot het stellen van de voorgestelde prejudiciële vragen. Zij betwist ook dat de prejudiciële vragen die reeds in het verzoekschrift werden vermeld, “beduidend” zouden zijn gewijzigd; ze zijn enkel aangepast qua bewoordingen om onder andere rekening te houden met het feit dat het *in casu* een vordering tot herstel in de “bijzondere sectoren” betreft. Zij benadrukt voorts dat het feit dat een vraag tot prejudiciële verwijzing in de laatste memorie wordt gesteld, geen geldige weigeringsgrond vormt om aan de verwijzingsplicht te verzaken. Zij betwist ook dat er louter sprake zou zijn van een verwijzingsmogelijkheid en tevens dat de Raad van State niet in laatste aanleg zou oordelen. De verzoekende partij wenst nogmaals te herhalen dat de uitzonderingen om af te wijken van deze verwijzingsplicht *in casu* niet zijn vervuld. Zij bemerkt hierbij dat de

mogelijkheid van een prejudiciële vraag in een burgerlijke procedure opnieuw een inbreuk zou vormen op artikel 6 van het EVRM omdat de verzoekende partij eventueel pas in een cassatievoorziening enige (relatieve) zekerheid zou hebben dat deze vragen zouden worden gesteld en in dat geval zou de redelijke termijn ruimschoots verstreken zijn, zeker gelet op het feit dat de Raad van State nu reeds de mogelijkheid heeft om de discussie te beslechten via een prejudiciële vraag.

Bovendien meent zij dat, voor zover er effectief geen sprake zou zijn van een plicht, doch louter van een mogelijkheid, *quod non*, een zorgvuldig rechtscollege geplaatst in dezelfde omstandigheden in het licht van de uiteenzetting in de procedurestukken van de verzoekende partij, minstens de betrokken vragen zou moeten stellen ook als dit niet verplicht zou zijn.

Beoordeling

18. Artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State luidt:

“Elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing, met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang.

Het verzoek tot schadevergoeding wordt uiterlijk ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.

[...]

De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, kan geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te bekomen.

Elke partij die een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering instelt of heeft ingesteld, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak geen vergoeding voor hetzelfde nadeel meer vragen.”

Artikel 25/1 van het algemeen procedurereglement luidt:

“Het in artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten bedoelde verzoek tot schadevergoeding tot herstel kan geformuleerd worden:

1° gelijktijdig met het beroep tot nietigverklaring;

2° of tijdens de procedure tot nietigverklaring;

3° of ten laatste binnen de zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.”

19. Krachtens de hiervoor aangehaalde bepalingen kan een verzoevende partij “die de nietigverklaring [...] vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3” aan de Raad van State vragen om haar een schadevergoeding toe te kennen, en kan dit verzoek tot schadevergoeding maar worden geformuleerd ofwel gelijktijdig met een beroep tot nietigverklaring, ofwel tijdens de procedure tot nietigverklaring ofwel ten laatste binnen de zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.

20. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 januari 2014 ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’ die artikel 11*bis* in de gecoördineerde wetten op de Raad van State heeft ingevoegd, kan worden gelezen dat deze nieuwe bevoegdheid van de Raad van State toelaat dat de partij “die een onwettigheid door de Raad van State heeft laten vaststellen”, kan vermijden vervolgens de zaak bij een burgerlijke rechtbank aanhangig te moeten maken om een vergoeding te verkrijgen voor het geleden nadeel (*Parl.St.* Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 6). De vereiste van een arrest waarbij de onwettigheid wordt vastgesteld als voorwaarde voor de toekenning van een schadevergoeding tot herstel, wordt – anders dan de verzoevende partij het ziet – ook reeds door de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies uitdrukkelijk onderschreven.

Zoals uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is bevestigd, valt een verzoek tot het verkrijgen van een schadevergoeding tot herstel slechts

onder de rechtsmacht van de Raad van State indien, onder meer, een arrest voorligt waarbij de onwettigheid van de bestreden beslissing wordt vastgesteld (zie Cass. 15 september 2017, AR C.15.0465.F).

21. In dit geval heeft de Raad van State bij arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019 het beroep ingesteld door de huidige verzoekende partij verworpen bij gebrek aan de vereiste hoedanigheid en het rechtens vereiste persoonlijk en rechtstreeks belang.

Aldus heeft de Raad van State in zijn voormelde arrest niet de onwettigheid van de bestreden beslissing vastgesteld, en werd het voorliggend verzoek niet ingediend ten laatste binnen de zestig dagen na de kennisgeving van het arrest “waarbij de onwettigheid werd vastgesteld”.

22. De omstandigheid dat artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State niet vereist dat een vernietigingsarrest is tussengekomen en de bestreden handeling wordt vernietigd, zoals de verzoekende partij bepleit, is weliswaar juist, doch neemt niet weg dat een arrest dient voor te liggen waarbij de onwettigheid van de bestreden beslissing wordt vastgesteld, hetgeen te dezen niet het geval is.

De argumentatie van de verzoekende partij kan evenmin steun vinden in de arresten nrs. 241.865 en 241.866 van 21 juni 2018 van de Algemene Vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waar de verzoekende partij naar verwijst. In die arresten wordt immers slechts geoordeeld dat “de omstandigheid dat de verzoekende partij in de loop van het geding haar belang bij de vernietiging verloren heeft, de Raad van State, wanneer een onwettigheid wordt vastgesteld, niet belet het verzoek tot schadevergoeding tot herstel te onderzoeken, voor zover voldaan is aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het beroep tot nietigverklaring op de dag waarop het wordt ingesteld”. Te dezen echter heeft de Raad van State in het arrest nr. 243.820 reeds

vastgesteld dat het annulatieberoep *ab initio* onontvankelijk was, zodat deze arresten niet dienstig kunnen worden aangevoerd.

In het arrest nr. 244.015 van 22 maart 2019 inzake Moors, waar de verzoekende partij eveneens naar verwijst, bevestigt de voornoemde Algemene Vergadering bovendien uitdrukkelijk het volgende:

“12. In alle gevallen is voor de toekenning van de schadevergoeding tot herstel vereist dat er een onwettigheid wordt vastgesteld in een arrest van de Raad van State dat uitspraak doet over een beroep tot nietigverklaring bedoeld in artikel 14, § 1 of § 3, van de Raad van State-wet.

13. Werd geen vordering tot schadevergoeding tot herstel aangespannen in de loop van de procedure tot nietigverklaring, dan moet die vordering, om ontvankelijk te zijn, worden ingesteld ‘zestig dagen na de kennisgeving van het arrest [over een beroep tot nietigverklaring] waarbij de onwettigheid werd vastgesteld’ – wat veronderstelt dat een dergelijk arrest reeds voorhanden is (artikel 11bis, tweede lid, van de Raad van State-wet; artikel 25/3 van het algemeen procedurereglement).”

Het standpunt van de verzoekende partij dat het zou volstaan dat zij de nietigheid heeft “benaarstigd” en erom heeft “verzocht” vindt dan ook geen grondslag in artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 25/1 van het algemeen procedurereglement, noch in de parlementaire voorbereiding, noch in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State.

23. Het voorliggend verzoek tot het verkrijgen van een schadevergoeding tot herstel voldoet bijgevolg niet aan de voorwaarden die vervuld dienen te zijn opdat de Raad van State zich over dit verzoek zou mogen uitspreken.

24. Wat de argumentatie van de verzoekende partij betreft dat de interpretatie en rechtspraak van de Raad van State omtrent artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State *in casu* niet ter zake doen omdat de artikelen 16 en 24 van de rechtsbeschermingswet een aparte en voldoende

rechtsgrond zouden bieden voor het onderhavig verzoek tot schadevergoeding tot herstel, kan deze geen steun vinden in de tekst van deze bepalingen zelf.

Beide bepalingen werden gewijzigd bij wet van 16 februari 2017 ‘tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ (hierna: wet van 16 februari 2017) om “de gevolgen in aanmerking [te nemen] van de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State voor de bepalingen van dezelfde wet betreffende de rechtsmiddelen en de verhaalinstanties en, met name, de bepalingen betreffende de schorsing, de schadevergoeding en de bevoegde verhaalinstanties”. Nergens uit deze bepalingen, noch uit de parlementaire voorbereiding bij deze bepalingen, blijkt dat de wetgever, wanneer er een schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State wordt gevorderd, beoogde af te wijken van de vereiste, overeenkomstig artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, dat een arrest dient voor te liggen waarbij de onwettigheid van de bestreden beslissing wordt vastgesteld en dat de vordering tot schadevergoeding tot herstel dient te worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen na de kennisgeving van het arrest waarin de onwettigheid wordt vastgesteld. Integendeel wordt dit in de parlementaire voorbereiding bij de wet van 16 februari 2017, waarbij de rechtsbeschermingswet werd gewijzigd, uitdrukkelijk bevestigd (*Parl.St.* Kamer 2016-17, nr. 2168/001).

Aldus dient rekening te worden gehouden met artikel 25, eerste lid, van de rechtsbeschermingswet dat bepaalt: “Tenzij de bepalingen van deze wet hiervan afwijken, worden de bevoegdheids- en procedurevoorschriften voor de verhaalinstantie bepaald door de wetten en besluiten betreffende de verhaalinstantie”. Dat dit anders is wat het aanvangspunt van de beroepstermijn betreft, zoals de Raad van State heeft bevestigd in zijn arrest nr. 233.367 van 29 december 2015, waar de verzoekende partij naar verwijst, doet geen afbreuk aan hetgeen hiervoor is vastgesteld, namelijk dat de wetgever in de

rechtsbeschermingswet, wat het instellen van een vordering tot schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State betreft, niet beoogde af te wijken van artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

25. De verzoekende partij betoogt voorts dat ook artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State in een grondwets- en richtlijnconforme interpretatie, tot de ontvankelijkheid van het voorliggend verzoek tot schadevergoeding tot herstel moet leiden, gelet op de volgens haar opkomende rechtspraak van de burgerlijke rechtbanken die tot de onontvankelijkheid besluit van schadeclaims indien deze niet worden voorafgegaan door een effectieve nietigverklaring. Zij benadrukt in de laatste memorie dat dit een omstandigheid uitmaakt waarmee rekening moet worden gehouden in het licht van de naleving van het recht op toegang tot de rechter.

Anders dan de verzoekende partij dit ziet, verschilt de voorliggende zaak wel degelijk van de zaak die geleid heeft tot het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 mei 2010, nrs. C-145/08 en C-149/08 inzake Club Hotel Loutraki. Artikel 5 “Vordering tot schadevergoeding” van de Griekse wet 2522/1977 bepaalt immers uitdrukkelijk dat “2. Voor de toekenning van schadevergoeding is vereist dat het bevoegde gerecht het onrechtmatige besluit of het onrechtmatige verzuim om een besluit te nemen vooraf nietig heeft verklaard of de nietigheid ervan heeft vastgesteld”.

Overeenkomstig artikel 2.6 van de richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 ‘houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken’ en artikel 2.1 van de richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 ‘tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer

en telecommunicatie' kunnen de lidstaten bepalen dat, wanneer schadevergoeding wordt gevorderd omdat het besluit onwettig is genomen, het aangevochten besluit eerst nietig moet worden verklaard door een instantie die daartoe bevoegd is. De voormelde bepalingen van de rechtsbeschermingsrichtlijnen bevatten aldus uitsluitend een mogelijkheid om te eisen dat in geval van een vordering tot schadevergoeding het betrokken besluit eerst nietig moet worden verklaard, doch geen verplichting hiertoe. Vastgesteld dient echter te worden dat de Belgische wetgeving, anders dan de Griekse wetgeving, geen vergelijkbare bepaling bevat.

De verzoekende partij steunt haar argumentatie bovendien louter op een bepaalde rechtspraak, die uitgaat van eenzelfde afdeling van een rechtbank van eerste aanleg, doch legt geen rechtspraak voor van andere rechtbanken, laat staan van hoven van beroep en van het Hof van Cassatie die deze visie zouden bevestigen. De verwerende partij van haar kant verwijst in haar laatste memorie integendeel naar een arrest van 20 september 2019 van het Hof van beroep te Gent waarin deze argumentatie aangaande de noodzakelijkheid van een voorafgaande nietigverklaring door de Raad van State, wordt ontkracht, en ook in het arrest van 13 december 2019 van datzelfde Hof waar de verzoekende partij zelf naar verwijst in haar pleitnota, neemt het Hof uitdrukkelijk afstand van de voormelde alleenstaande lagere rechtspraak.

Ook blijkt niet dat in de voormelde vonnissen reeds rekening werd gehouden met de artikelen 16 en 24 van de rechtsbeschermingswet, zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017, gelet op de nieuwe bevoegdheid van de Raad van State inzake de schadevergoeding tot herstel. In de memorie van toelichting bij de wet van 16 februari 2017 wordt onder meer uitdrukkelijk bevestigd dat “schadevergoeding tot herstel steeds afhankelijk [is] van het bestaan van een verhaal tot vernietiging, terwijl de vordering tot schadevergoeding niet noodzakelijk daarmee verband moet houden” (*Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2168/001, 29*).

Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet blijkt ook duidelijk dat de wetgever bij de invoering van artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State uitdrukkelijk beoogde om de partijen die dit wensen de mogelijkheid te laten behouden om zich, zoals dat voorheen het geval was, tot de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde te wenden om een herstel te krijgen op grond van de artikelen 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

Ook het Grondwettelijk Hof heeft bevestigd dat een vordering tot het verkrijgen van een schadevergoeding tot herstel op meerdere punten verschilt van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering, en een eerste verschil betrekking heeft op het toepassingsgebied: “een gemeenrechtelijke schadevergoeding [kan] ten laste van de overheid worden gevorderd ongeacht de grondslag van de procedure bij de Raad van State en zelfs los van enige procedure bij de Raad van State” (*GwH* 23 mei 2019, nr. 70/2019, overweging B.7.2). Anders dan de verzoekende partij het ziet, is deze overweging ook relevant in het overheidsopdrachtencontentieux.

26. In het arrest nr. 244.015 van 22 maart 2019 inzake Moors oordeelde de Algemene Vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bovendien reeds dat er geen sprake is van een ongelijke behandeling van verzoekende partijen die er zelf voor kiezen om geen vordering tot schadevergoeding tot herstel in de loop van hun beroep tot nietigverklaring in te dienen. Ook bevestigde de Raad in dit arrest dat een verzoekende partij die hangende haar beroep tot nietigverklaring geen vordering tot schadevergoeding instelt, na de uitspraak over het beroep tot nietigverklaring ten minste over de mogelijkheid blijft beschikken om een schadevergoeding bij de rechtbanken van de rechterlijke orde op te eisen.

Het standpunt van de verzoekende partij dat het voornoemde arrest Moors strijdig zou zijn met het arrest van het Hof van Cassatie van 7 mei

2018, AR C.16.0516.F wordt evenmin gevolgd aangezien zij daarbij uit het oog blijkt te verliezen dat de schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State een *accessorium* is van een annulatieberoep. *In casu* heeft de verzoekende partij geen vordering tot toekenning van een schadevergoeding tot herstel ingesteld in de loop van de annulatieprocedure, zodat zij van de Raad van State hoe dan ook geen beoordeling van haar middelen mag verwachten louter met het oog op het faciliteren van de eventuele toekenning van een schadevergoeding.

Ondanks het feit dat de Raad van State in het arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019, vaststellende dat de verzoekende partij lopende het annulatieberoep geen schadevergoeding voor de Raad van State heeft gevorderd, uitdrukkelijk opgemerkt heeft dat de verzoekende partij alsnog haar subjectief recht op schadevergoeding bij de gewone rechter kan laten gelden, blijkt de verzoekende partij zich na dit arrest bovendien niet tot de gewone rechter te hebben gericht, maar alsnog een schadevergoedingsvordering tot herstel bij de Raad van State heeft ingesteld die niet inpasbaar blijkt te zijn in de voor de Raad van State geldende toepasselijke regelgeving zoals hiervoor werd uiteengezet.

Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat de Raad van State in zijn rechtspraak reeds bevestigd heeft dat de zogenaamde *electa-una-viaregel*, gelet op de interne samenhang van het bedoelde wetsartikel, slechts toepassing heeft in het geval door de Raad van State bij arrest een onwettigheid is vastgesteld. De Raad van State relateert het onherroepelijk karakter van het *electa-una-viaprincipe* indien het annulatieberoep onontvankelijk is.

27. Het is niet mogelijk om via de voorliggende vordering tot schadevergoeding tot herstel, die pas werd ingesteld nadat een eindarrest in het kader van het annulatieberoep werd gewezen, het arrest waarin uitspraak wordt gedaan over het annulatieberoep te herzien. Het annulatieberoep werd definitief beslecht door het arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019, dat bekleed is met

gezag van gewijsde, zodat de verzoekende partij op deze zaak niet vermag terug te komen in het kader van de voorliggende zaak.

Voor beroepen tot herziening geldt voorts een specifieke procedure. De voorliggende vordering betreft een schadevergoeding tot herstel, geen verzoek tot herziening tegen het arrest nr. 243.820.

Overeenkomstig artikel 31 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is een dergelijk beroep tot herziening bovendien slechts ontvankelijk indien sinds de uitspraak van het arrest doorslaggevende stukken zijn teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij waren achtergehouden of indien het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde stukken.

De verwijzing naar nieuwe rechtspraak die inmiddels werd gewezen, zoals de verzoekende partij doet in haar verzoekschrift en memorie van wederantwoord, wordt niet als grond tot herziening vermeld.

Ook overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van 29 juli 2019, nr. C-620/17 inzake Hochtief Solutions AG (...), moet enkel van de mogelijkheid om op een in kracht van gewijsde gegaan vonnis terug te komen, teneinde de uit dit vonnis voortvloeiende situatie in overeenstemming te brengen met een eerdere definitief geworden nationale rechterlijke beslissing waarvan de rechter die dit vonnis heeft gewezen en de partijen in de betrokken zaak reeds op de hoogte waren, worden gebruikgemaakt indien de toepasselijke nationale procedureregels de nationale rechter die mogelijkheid bieden. De verzoekende partij beweert niet en toont niet aan dat de toepasselijke nationale procedureregels dergelijke mogelijkheid bieden. In de mate dat de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord nog verwijst naar de zaak nr. C-362/18, waarin het Hof van Justitie inmiddels op 18 december 2019 een beschikking heeft gewezen, valt op te merken dat de voorliggende vordering geen beroep tot herziening betreft, noch betrekking heeft op staatsaansprakelijkheid.

28. De exceptie is gegrond. Het verzoek is niet ontvankelijk.

VI. Verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen

Standpunt van de verzoekende partij

29. Voor het geval dat de Raad van State oordeelt – zoals hiervoor is gebeurd – dat de voorliggende vordering niet ontvankelijk is, vraagt de verzoekende partij om volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen, zoals geherformuleerd in haar memorie van wederantwoord:

“Zijn artikelen 16 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, samen genomen met artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wanneer deze laatste optreedt als beroepsinstantie in de zin van artikel 2.2 van de richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, verenigbaar met artikelen 2.1.b), 2.1.c) en 2.1.d) van dezelfde richtlijn, gelezen in het licht van artikel 47 van het Handvest van de EU, wanneer deze zodanig worden toegepast dat ze enkel toelaten aan de gezamenlijke leden van een tijdelijke handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die als zodanig heeft deelgenomen aan een procedure voor de gunning van een overheidsopdracht en waaraan deze opdracht niet is gegund, om op ontvankelijke wijze een nietigverklaring te kunnen vorderen van een besluit van een aanbestedende overheid in een gunningsprocedure, maar dat dit recht wordt ontzegd aan één van [de] individuele leden van dergelijke tijdelijke handelsvennootschap, terwijl deze nog niet is opgericht, en wanneer dit tot gevolg heeft dat dergelijk individueel lid automatisch ook geen schadevergoeding kan vorderen bij dezelfde beroepsinstantie?

Is het antwoord op deze vraag verschillend wanneer het toekennen van een schadevergoeding bedoeld in artikel 2.1, d) van dezelfde richtlijn ook kan worden gevorderd bij de burgerlijke rechtbanken, in de wetenschap dat (a) sommige van deze burgerlijke rechtbanken de toegang tot dergelijke vordering afhankelijk maken van een voorafgaande nietigverklaring door de Raad van State en (b) er relevante verschillen zijn tussen de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State wat betreft dubbele aanleg,

vereenzelviging van onwettigheid en fout, doorlooptijd, en cassatiemogelijkheid?”

De verzoekende partij betoogt dat er sprake is van een verwijzingsplicht in hoofde van de Raad van State en dat de restrictief te interpreteren uitzonderingen op deze verwijzingsplicht *in casu* niet van toepassing zijn. Zo is de vraag omtrent de ontvankelijkheid van de voorliggende vordering onlosmakelijk verbonden met de naleving van het relevante EU-recht, en dus wel degelijk pertinent voor de oplossing van het huidig geschil. Voorts betwist zij dat deze vraag een *acte éclairé* zou betreffen. De vraag die voorligt in de voorliggende casus lijkt in geen enkel relevant opzicht nog op de vraag die voorlag in de zaak Espace Trianon. *In casu* betreft het immers geen nietigverklaringsprocedure, maar een vordering tot schadevergoeding. Ondertussen zijn er ook talloze nieuwe arresten van het Hof van Justitie over de rechtsbeschermingsrichtlijnen die minstens een toetsing door het Hof van Justitie vereisen alvorens de Raad de voorliggende vordering mag afwijzen wegens onontvankelijk. Ook is deze vraag niet dezelfde als de vraag die voorlag in de voorafgaande procedure tot nietigverklaring, waarin de bestaanbaarheid van artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State met de rechtsbeschermingsrichtlijnen, zoals toegepast bij het overheidsopdrachten-contentieux met betrekking tot het belang van individuele leden van een tijdelijke handelsvennootschap, aan de orde was. Tevens meent zij dat de nieuwe bevoegdheid van de Raad om een schadevergoeding toe te kennen wel degelijk een pertinent element is dat een nieuwe vraagstelling verantwoordt. De wetgever wenste via deze weg immers te vermijden dat “een nieuwe rechter heel het dossier opnieuw (moet) bestuderen, wat opnieuw gerechtskosten en proceduretermijnen met zich meebrengt”. Ten slotte is er evenmin sprake van een *acte clair*. Gelet op de uitvoerige uiteenzettingen over de betrokken bepalingen door beide partijen in de nietigheidsprocedure en in de voorliggende procedure tot schadevergoeding tot herstel, is het duidelijk dat deze voorwaarde niet is vervuld om een prejudiciële verwijzing te weigeren.

De verzoekende partij merkt ook nog op dat er momenteel een verzoek hangende is voor het Hof van Justitie dat tevens relevant kan zijn voor de oplossing van onderhavig geschil. Het betreft de zaak nr. C-362/18.

30. Eveneens in ondergeschikte orde vraagt de verzoekende partij om volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, zoals geherformuleerd in haar memorie van wederantwoord:

“Zijn artikelen 16 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, samen genomen met artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, elk individueel en gezamenlijk bekeken, gelezen in het licht van artikel 6 EVRM en artikel 47 van het Handvest van de EU, verenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer zij zodanig worden toegepast dat één individueel lid van een tijdelijke handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die als zodanig heeft deelgenomen aan een procedure voor de gunning van een overheidsopdracht en waaraan deze opdracht niet is gegund, niet op ontvankelijke wijze de nietigverklaring bij de Raad van State kan vorderen van een gunningsbeslissing van een aanbestedende overheid in een overheidsopdrachtenprocedure in toepassing van artikel 24, 1° van de wet van 17 juni 2013 wanneer dit tot gevolg heeft dat dergelijk individueel lid automatisch ook geen schadevergoeding kan vorderen bij dezelfde Raad van State, terwijl dit recht niet wordt ontzegd aan een individueel lid van een tijdelijke handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die een annulatieberoep instelt bij de burgerlijke rechtbank waarbij de aanbestedende overheid die de bestreden gunningsbeslissing heeft getroffen geen overheid is in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, rekening houdende met het bestaan van burgerlijke rechtspraak die een schadevergoeding afhankelijk maakt van een voorafgaandelijke vernietiging?”

De verzoekende partij betwist dat de vraag vertrekt van een verkeerde premisse, gelet op het bestaan van vier afzonderlijke vonnissen. Deze burgerlijke rechtspraak, die overigens grondig onderbouwd is en volgens haar ook door sommige rechtsleer wordt ondersteund, dient dus wel degelijk in aanmerking te worden genomen als relevant feit voor een correcte beoordeling van de onderhavige zaak, en moet dus eventueel tevens het voorwerp uitmaken van een prejudiciële verwijzing naar het Grondwettelijk Hof.

Beoordeling

31. Wat de in ondergeschikte orde voorgestelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof betreft, dient in de eerste plaats vastgesteld te worden dat de verzoekende partij deze vragen nog beduidend heeft geherformuleerd in haar memorie van wederantwoord, hetgeen afbreuk doet aan een loyale procesvoering. Het is evident dat de verwerende partij zich in haar memorie van antwoord slechts heeft kunnen verweren op de vragen zoals deze in het oorspronkelijk verzoekschrift werden geformuleerd. Van de verzoekende partij mocht dan ook worden verwacht dat zij de voorgestelde prejudiciële vragen reeds in het verzoekschrift zodanig had geformuleerd om deze te laten aansluiten op de voorliggende procedure van een verzoek tot schadevergoeding tot herstel en niet pas in de memorie van wederantwoord.

Bovendien steunen zowel de aan het Hof van Justitie als de aan het Grondwettelijk Hof voorgestelde prejudiciële vragen op de premisse dat er voor de verzoekende partij geen beroep tot schadevergoeding voor de gewone hoven en rechtbanken openstond zonder voorafgaandelijke vernietiging. Zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, wordt het uitgangspunt waarop de verzoekende partij haar vragen steunt, echter niet aangetoond.

Indien een verzoekende partij in een dergelijk geval voor de gewone hoven en rechtbanken alsnog met afwijkende rechtspraak zou worden geconfronteerd, staat het haar bovendien vrij om aldaar vragen voor te stellen aan het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof.

De voorgestelde vragen aan het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof zijn ook niet prejudicieel aangezien in het voorliggend beroep geen uitspraak dient te worden gedaan over de ontvankelijkheid van een annulatieberoep, noch over een verzoek tot schadevergoeding tot herstel dat werd ingesteld samen met of gedurende het annulatieberoep. Bovenal is de voorliggende vordering niet ontvankelijk om reden dat ze niet overeenkomstig

voornoemd artikel 25/1 van het algemeen procedurereglement werd ingesteld binnen de zestig dagen na de kennisgeving van een arrest waarbij een onwettigheid werd vastgesteld. Het antwoord op de prejudiciële vragen heeft dan ook geen invloed op de oplossing van het geschil.

Overigens is, anders dan de verzoekende partij het ziet, de Raad van State krachtens artikel 26, § 2, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 ‘op het Grondwettelijk Hof’ niet in elk geval gehouden tot die vraagstelling. De Raad van State beslist te dezen aldus van het verzoek geen kennis te kunnen nemen zodat het onderhavig arrest nog vatbaar is voor een voorziening bij het Hof van Cassatie bij toepassing van artikel 33, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De door de verzoekende partij voorgestelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof worden niet gesteld.

VII. Slotsom

32. Uit wat voorafgaat, volgt dat niet is voldaan aan de voorwaarden die vervuld dienen te zijn opdat de Raad van State zich over het voorliggend verzoek tot het verkrijgen van een schadevergoeding tot herstel zou mogen uitspreken.

BESLISSING

1. De Raad van State verwierpt het verzoek tot schadevergoeding tot herstel.

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van het verzoek tot schadevergoeding tot herstel, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van vijf november tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Dierk Verbiest,	kamervoorzitter,
Pierre Barra,	staatsraad,
Patricia De Somere,	staatsraad,
bijgestaan door	
Greta Scheveneels,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Greta Scheveneels

Dierk Verbiest